

0004850-26.2018.8.26.0048

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberta Layaun Chiappeta de Moraes Barros

Comarca: Atibaia

Foro: Foro de Atibaia

Vara: 1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... a consumo de sua amiga.

Por si só, a conduta já consubstanciou tráfico de entorpecentes, senão vejamos:

O artigo 33 da Lei 11.343/06 não define como necessário, para a consumação de suas figuras típicas, o caráter comercial do tráfico. Aliás, sequer delimita qualquer definição para "traficante", limitando-se a descrever figuras típicas que, praticadas, ensejam ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia

Foro de Atibaia

1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Rua Doutor José Roberto Paim, 99, Atibaia - SP - cep 12945-007

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0004850-26.2018.8.26.0048 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0004850-26.2018.8.26.0048

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SIMONE DE ARAUJO PORTO e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Roberta Layaun Chiappeta de Moraes Barros

SIMONE DE ARAUJO PORTO e ALINE FERNANDA SIQUEIRA MASCHIETTO, qualificadas nos autos, foram denunciadas como incursoas nas penas do artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque conforme denúncia oferecida pelo Ministério Público, no dia 19 de maio de 2018, por volta das 12h30min, na Av. Horácio Neto, 357, Pq. Residencial, nas dependências de estabelecimento hospitalar psiquiátrico destinado à reabilitação de dependentes químicos, denominado "Comunidade Terapêutica Maxwell", em Atibaia, SIMONE trouxe consigo e entregou a ALINE, 02 cigarros de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda conforme a denúncia, logo em seguida, mas ainda nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, ou seja, no interior do referido estabelecimento hospitalar, ALINE FERNANDA SIQUEIRA MASCHIETTO, entregou ao consumo de Fernando Vital Buschi, 01 cigarro de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nos termos da exordial, em período de visita, a primeira ré trouxe consigo e entregou ao consumo da segunda ré - que estava internada no mencionado nosocômio justamente para se tratar de sua dependência química de entorpecentes - dois

cigarros de maconha. É certo, ademais, que ALINE havia previamente solicitado a droga a SIMONE, por meio de mensagens de aplicativo de celular, WhatsApp. Logo na sequência, ALINE entregou um dos cigarros de cânhamo ao consumo de outro paciente que se encontrava internado pelo mesmo motivo no local.

Conforme constou da denúncia, ALINE e SIMONE saíram para almoçar. Enquanto isso, porém, o paciente a quem ALINE entregara um dos cigarros passou a fazer uso da droga no interior de seu quarto, acompanhado de outros pacientes não identificados. A preambular narrou que funcionários da clínica sentiram o odor característico da queima da erva nas dependências do estabelecimento e passaram a fazer buscas por quem estaria usando. Quando finalmente entraram no quarto do usuário, este já havia consumido inteiramente a droga, porém apresentava claros e característicos sinais de entorpecimento, tais como olhos avermelhados e fala mole. Ademais, ao ser questionado, admitiu que havia acabado de consumir um cigarro de maconha que lhe havia sido entregue por ALINE.

A exordial apontou que ao ser questionada pelos funcionários da clínica, ALINE confirmou que havia recebido os cigarros de maconha da amiga, e lhes entregou um dos cigarros, ainda não consumido. O paciente Fernando foi submetido a exame toxicológico, que confirmou o uso de maconha.

A denúncia indicou que os crimes praticados pelas rés foram ambos cometidos no interior de estabelecimento hospitalar.

A denúncia foi oferecida (fls. 166/168). A ré SIMONE foi notificada (fls. 188) e apresentou defesa preliminar (fls. 189/199); ALINE, não encontrada pessoalmente, foi notificada por edital (fls. 250/253), sendo-lhe indicado defensor, que apresentou defesa preliminar (fls. 261). Ambas as defesas foram afastadas, sendo a denúncia recebida, por decisão que determinou a citação das acusadas (fls.

262/265). SIMONE foi citada pessoalmente (fls. 308), enquanto ALINE foi citada por edital (fls. 281/283 e 301/302). Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas quatro testemunhas, sendo a ré SIMONE ouvida ao final. O processo teve o andamento suspenso quanto à ré ALINE, com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 470).

Em memoriais, a representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal com relação à corré SIMONE, entendendo provados os fatos narrados na denúncia (fls. 428/439).

A defesa de SIMONE requereu, em síntese, reconhecimento de atipicidade da conduta perpetrada pela ré, considerada a ausência de finalidade mercantil em sua ação, que ensejou a apreensão de um cigarro de maconha. Pontuou que as testemunhas ouvidas não foram capazes de comprovar que a ré teria fornecido o cigarro de maconha para os pacientes da clínica e que nenhum elemento probatório indicou que a acusada, ao levar o cigarro de maconha para fumar junto com sua amiga, tinha a intenção de comercializá-lo, ainda que gratuitamente, no local. Sustentou sua tese fazendo análise dos depoimentos colhidos e concluiu que a intenção da ré e de sua amiga era a de fumar o cigarro de maconha juntas, não havendo, assim, que se falar em tráfico de drogas. Defendeu, ainda, o princípio da insignificância, apontando que, não obstante não comprovada a finalidade mercantil, a quantidade de maconha apreendida, ou seja, 1,1g, não tem o condão de ofender o bem jurídico tutelado pela Lei de Drogas. Postulou a absolvição da ré com fundamento no artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal. Alternativamente, requereu a desclassificação da conduta pela qual a ré foi denunciada para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, elaborando raciocínio que concluiu que, levando-se em consideração a natureza e quantidade de drogas apreendida, bem como a forma com a qual a ação se desenvolveu, a droga se destinava ao consumo pessoal da ré. Para o caso de condenação, defendeu a desclassificação da conduta para a prevista no parágrafo 3º do artigo 33 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, para o caso de condenação pelo crime pelo qual a ré foi denunciada, requereu a fixação da pena no mínimo legal e aplicação do redutor previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo.

Requereu, também, a compensação da confissão espontânea e da minorante prevista no parágrafo 4º, acima mencionada, com a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III da mesma Lei. Requereu fixação de regime mais brando para cumprimento de pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de

direitos (fls. 449/469).

É o relatório.

Passo a decidir.

Preliminarmente, defiro o desmembramento requerido pela representante do Ministério Público em memoriais. Providencie a Z. Serventia o quanto necessário.

Passo a sentenciar o feito quanto à ré SIMONE. E quanto a tal acusada, a ação penal é procedente.

A materialidade criminosa está consubstanciada no boletim de ocorrência (fls. 04/05), no auto de exibição e apreensão (fls. 09), no laudo toxicológico (fls. 34/35) e na prova oral produzida.

A autoria criminosa deve ser imputada a ré SIMONE que, interrogada extrajudicialmente (fls. 44/45), disse que conhece ALINE, a quem considera sua melhor amiga, tendo sido madrinha do casamento dela; na época dos fatos, ALINE estava internada para tratamento de vício de cocaína e álcool e, no dia 19 de maio de 2018 foi visitar ALINE no estabelecimento em questão; ALINE lhe pediu para levar um casaco, o qual estava em sua posse, uma vez que dentro do casaco havia dois cigarros artesanais de maconha que tinham sido adquiridos por ALINE numa festa de casamento; até o pedido de ALINE não tinha conhecimento de que havia tal tipo de substância ali dentro; o casaco estava em sua posse porque o pediu para ALINE numa festa; quando chegou ao hospital, entregou o casaco para ALINE; ALINE chegou a verificar se os dois cigarros estavam ali, deixando-os no mesmo lugar, decidindo voltar depois para fumá-los em sua companhia [da depoente]; afirmou que de vez em quando também faz uso de maconha; saíram para almoçar; deixaram os cigarros para fumarem juntas depois, no jantar, fora da clínica, porque ALINE tinha receio de voltar na hora do almoço, quando realizaria alguns exames; quando retornaram do almoço, o médico responsável do hospital abordou ALINE, indagando-a a respeito da origem de um cigarro de maconha que foi encontrado em poder de um paciente; tal paciente, cuja nome não sabe dizer, teria sido flagrado fumando maconha e afirmou ter pegado tal cigarro dentro do quarto de ALINE; ALINE confirmou que havia pedido para sua pessoa [a depoente] levar o casaco dela, onde estavam os cigarros, para o hospital, pois entendia que estava no local para se tratar de outros vícios, não do de maconha; após ter sido humilhada pelo médico responsável pelo hospital, foi embora e nunca mais voltou para aquele local; negou ter adquirido a maconha encontrada dentro do casaco de ALINE, afirmando que a substância em questão era de sua amiga; diz também que nunca teve a intenção de prejudicar sua amiga e que aquela foi a primeira vez que esteve no hospital; diz desconhecer se outras pessoas chegaram a levar drogas para ALINE durante o período em que ela ficou internada naquele hospital.

Em juízo, a ré SIMONE confessou o delito, assumindo ter levado os cigarros de maconha a pedido de ALINE; confirmou que sabia que a corré estava internada para fins de tratamento, tendo dito, entretanto, que tal tratamento era por dependência de álcool e cocaína, não de maconha; indagada se considerou normal levar maconha para a pessoa em tratamento, respondeu que ela lhe pediu, razão pela qual levou, afirmando que não teve intenção de prejudicá-la, nem à clínica; indagada sobre ter ocultado a droga dentro de um buquê, respondeu que não teve buquê, explicando que levou o entorpecente dentro de uma jaqueta que a própria ALINE havia lhe emprestado; é cabeleireira, aufera R\$ 4 mil por mês e estudou até o ensino médio; nunca foi processada; levou dois cigarros de maconha, já em formato de cigarro, a pedido de ALINE; indagada por sua defesa sobre o motivo pelo qual ALINE lhe pediu para levar o cigarro de maconha, respondeu que ela pediu para levar para usarem juntas, na hora do jantar; indagada se não sabia que terceiro faria uso da droga, respondeu que não sabia de jeito nenhum; confirmou já ter fumado maconha algumas vezes com ALINE; explicou que entregou a jaqueta para ALINE e que ela a guardou no quarto dela, sendo que saíram para almoçar em seguida; ao voltarem, Dr. Sabino lhe disse que alguém havia entrado no quarto de ALINE, havia pegado um cigarro de maconha e fumado lá dentro; ALINE confirmou o ocorrido; ALINE dormia sozinha no quarto dela; tem uma filha adotiva de dez anos e é solteira, sendo que sua filha reside com sua mãe, em Belém do Pará; pela defesa de ALINE foi indagado se alguém, na clínica, lhes informou que alguma pessoa entrou no quarto e pegou o cigarro, ou

se ALINE deu um cigarro para alguém, respondeu que disseram que alguém entrou no quarto de ALINE, pegou um cigarro e fumado; antes dos fatos, eram usuárias de maconha.

A testemunha Sabino Ferreira de Farias Neto, diretor da clínica Maxwell, confirmou que a ocorrência procede; explicou que os pacientes da clínica têm direito de contato com aqueles que quem os internou permitir; houve uma visita da mãe, do marido e de uma amiga de ALINE; anteriormente, ALINE solicitou, via WhatsApp, que a amiga lhe levasse maconha até ela, sendo que a amiga levou o entorpecente dentro de flores; ALINE saiu com a mãe e com o marido para almoçar; conseguiram pegar a droga, embora um paciente tenha feito o consumo; não presenciou a ocorrência, tendo presenciado quando as pessoas lhe levaram uma maconha; juntamente de outras duas pessoas que trabalhavam no local, à época, foram à delegacia entregar a droga e registrar a ocorrência; indagado pela acusação se houve apuração a respeito de ALINE ter levado um pouco da droga para Fernando, respondeu que conseguiram pegar parte da droga, pois Fernando fez uso, sendo que possuem exame toxicológico positivo para uso por parte de tal indivíduo; indagado se Fernando confirmou que quem lhe entregou a droga foi ALINE, respondeu que sim, sendo que ela própria confessou; não conversou com SIMONE e, ao que soube, ela sequer entrou na clínica; pela defesa de SIMONE foi indagado sobre o motivo de a ocorrência ter sido registrada somente dois dias após a ocorrência, ao que a testemunha respondeu não saber se foi dois dias depois, ou se no mesmo dia, esclarecendo que registraram a ocorrência quando constatarem e apuraram os fatos; indagado pela defesa de ALINE sobre o nome do funcionário que relatou os fatos para sua pessoa, respondeu não poder precisar, mas ao que se recordou, foram Marisa e Mariele; não se recordou, exatamente, o que cada uma lhe falou, tendo se recordado que lhe disseram ter constatado que uma visitante, a qual veio junto com o marido e mãe de ALINE, os quais saíram para com ela almoçar, trouxe maconha, droga que outro paciente também fez uso; indagado sobre qual teria sido a conduta de ALINE, em relação ao que foi dito, respondeu que ela foi expulsa da instituição; esclareceu que ela recebeu a droga da amiga e repassou para outro paciente, não sabendo dizer a quantidade repassada para Fernando; indagado se ALINE fez uso da substância, pelo que lhe contaram, respondeu que pelo que soube, sim; indagado se foi feito exame toxicológico em ALINE, respondeu não poder afirmar, esclarecendo que ela própria verbalizou ter feito uso; indagado se se recordava ter se tratado de grande ou pequena quantidade de entorpecente, respondeu não poder afirmar, explicando que o equivalente a um cigarro de maconha foi levado à polícia, sendo que o restante foi consumido; confirmou considerar ALINE como dependente química.

A testemunha Marielle Fernanda Santos Almeida, disse que estava na clínica em tal período; no dia em questão, foi chamada porque estava havendo uma movimentação no quarto dos pacientes; ao adentrar no quarto, sentiu um cheiro característico de maconha; perguntou o que estava acontecendo e os pacientes desconversaram; comunicou ao médico psiquiatra que estava acontecendo algo no quarto, sendo que havia dois pacientes no local; o médico decidiu por fazer um teste toxicológico para confirmar eventual uso; chamou o paciente para conversar e ele acabou confessando que havia feito uso; o próprio paciente também contou para o médico o ocorrido; indagada se o paciente comentou sobre quem havia fornecido a droga, respondeu que ele disse que havia feito o pedido através da paciente ALINE que, por sua vez, conseguiu a droga através da amiga dela; indagada sobre como a droga entrou na clínica, respondeu não se recordar sobre como ela entrou, não lembrando exatamente se foi por meio de um buquê; indagada se chegou a confrontar ALINE e SIMONE sobre o ocorrido, respondeu que o médico fez uma reunião na época; esclareceu que ALINE havia saído para almoçar com a família e a amiga, sendo que quando ela chegou, os fatos já haviam ocorrido, sendo que conversaram; ao que se recorda, ALINE havia feito o pedido; indagada se SIMONE admitiu que ALINE havia feito o pedido e que havia trazido drogas para ela, respondeu que sim; indagada pela defesa de ALINE sobre há quanto tempo trabalha na clínica, respondeu que trabalhou dois anos na clínica; indagada se já viu ocorrência semelhante na clínica, confirmou que já houve ocorrências semelhantes, afirmando que foram poucos casos; questionada se ALINE já tinha feito algum ato como este, respondeu que não;

perguntada sobre o comportamento de ALINE, respondeu que ela tinha um convívio bom com os demais pacientes e era uma paciente tranquila; indagada sobre quem era o responsável pela segurança, respondeu que quando o paciente vai entrar ou quando os familiares trazem algo para os pacientes, fazem a revista, só que no dia em questão, o buquê não foi entregue para a clínica efetuar a vistoria; quando se entra na clínica, é assinado um termo de responsabilidade, sendo que o visitante é avisado; indagada se foi feito exame toxicológico em ALINE, respondeu que não, pois ao que se recordou, a amiga de ALINE entrou e logo depois elas saíram, sendo que neste meio tempo, o paciente fez uso; não sabe dizer se ALINE fez uso ou não do entorpecente, pois ela saiu, não estava na clínica; sobre a descoberta, em si, explicou que foi alertada de que estavam reunidos num quarto, sendo que quando adentrou o recinto, perguntou o que era aquele cheiro - tendo sentido cheiro de maconha -, tendo reparado, ainda, no olho vermelho de um paciente; os pacientes desconversaram; indagada se viu quando ALINE voltou e se ela aparentava estar com os olhos vermelhos igual aos demais, respondeu que a viu e que ela não aparentava estar como os demais; indagada se as pessoas que geralmente se internam são pessoas viciadas ou traficantes, respondeu que são dependentes químicos.

A testemunha Marisa Renata Ferreira disse que é psicóloga e estava no plantão no estabelecimento, no dia da ocorrência; ALINE era paciente no local, estava internada e recebeu uma visita de SIMONE que, a princípio, era afilhada ou madrinha dela; SIMONE entrou com um grande buquê de Gérberas, envolto num invólucro rústico; como estava muito bem embrulhado, não suspeitou do buquê; a droga estava dentro do buquê; ela entrou com o buquê; três pacientes usaram a substância: ALINE, Fernando e Lucas; Lucas foi internado seis meses antes, em surto psicótico, tratando-se de um paciente muito jovem e esquizofrênico; ao longo do tratamento, ele foi melhorando e estava estabilizado; referido indivíduo, entretanto, era adicto, tinha vício em maconha; SIMONE distribuiu para ALINE, que pediu, para Fernando, que estava com ela e para Lucas, que visitou o quarto; Lucas teve uma piora absurda, retornando ao surto psicótico; indagada se SIMONE chegou a ser confrontada sobre os fatos, ou se já tinha ido embora quando descobriram, explicou que já havia ido embora; indagada se ALINE assumiu que pediu e que SIMONE levou, respondeu que sim; indagada se ALINE assumiu ter distribuído para Fernando e Lucas, respondeu que sim, tendo ALINE dito que foi um pedido de Fernando; questionada se ALINE fez tal pedido à SIMONE e esta prontamente atendeu, respondeu que sim; indagada pela defesa de ALINE sobre quem teria solicitado o entorpecente, se Fernando ou ALINE, respondeu que Fernando solicitou para ALINE, tendo ALINE dito que tinha uma amiga que podia trazer; confrontada com sua narrativa em solo policial, ocasião em que não falou que ALINE chegou a consumir o entorpecente, que ela teria apresentado, imediatamente, um cigarro de maconha e que o diretor da clínica teria dito que ALINE nem tivesse consumido a maconha, por não ter tido tempo para tanto, respondeu que o crime subsiste em ALINE ter distribuído o entorpecente numa clínica de tratamento, e não feito o consumo; indagada se saberia precisar a quantidade de droga que foi distribuída, respondeu que não se recordou, afirmando que foi o suficiente para deixar o paciente em surto; confrontada, pela defesa de SIMONE, com o depoimento que prestou em solo policial, ocasião em que disse que SIMONE confirmou que ALINE havia lhe pedido cigarros de maconha, os quais seriam destinados ao consumo próprio, e não para compartilhar com outros pacientes, respondeu não se recordar se ela falou isso, mas o fato foi que ela distribuiu; está se pautando nos fatos, ou seja, ela entrou com a droga e três pacientes consumiram; questionada se confirma o que disse em seu depoimento prestado em solo policial, respondeu que sim, dizendo crer que ela falou que era para consumo de ALINE, mas não foi o que aconteceu; indagada se presenciou a entrada da droga, respondeu que estava no plantão e presenciou, dizendo que se houve alguma falha de revista, foi sua, porque precisava ter verificado o buquê, mas não viu qualquer maldade no buquê, que nem vaso tinha.

A testemunha Fernando Vital Buschi declarou que estava presente, pois estava fazendo tratamento na clínica; presenciou ALINE recebendo de uma amiga dela, que não conhecia, três ou quatro cigarros de maconha; confirmou ter recebido um cigarro de ALINE; indagado se a corré passou cigarros para outras pessoas, respondeu que

não; indagado se Lucas estava em sua companhia, respondeu que ele estava no quarto com sua pessoa e também fumou; indagado se ALINE também fumou dentro do estabelecimento, respondeu que não, pois estava apenas com Lucas no local, sendo que ela estava em outro quarto; indagado se ela fumou em outro quarto, respondeu que sim; indagado se sabia o nome da amiga que levou os cigarros de maconha, respondeu saber porque está escrito no processo, ou seja, SIMONE, mas não a conhecia nem conversou com ela; indagado sobre como ela fez para entrar com os cigarros no estabelecimento, respondeu que ela levou dentro de um buquê de flores, ao que lhe parece; indagado a respeito da finalidade da clínica, respondeu que é uma clínica para tratamento de depressão e dependência química, por drogas ou álcool; indagado pela defesa de ALINE se alguém pediu este cigarro de maconha, respondeu que não se recorda de alguém ter pedido, sabendo dizer apenas que chegou lá; questionado sobre como o cigarro chegou em suas mãos, indagado se chegou a pedir, respondeu que estavam com problemas e se conheceram no local; não soube dizer qual foi o assunto que levou a comentarem sobre fumar, dizendo saber que chegou e sua amiga apareceu com um “baseado”; indagado se até então sabia que a ré era tão somente usuária e nada mais, respondeu “nada mais”, explicando que a ré foi se tratar porque estava com problemas com o ex-marido; indagado se já houve, naquele local, outro caso de suposto tráfico de drogas, respondeu que só houve esta ocorrência; perguntado se ALINE era uma pessoa tranquila, se ela nunca tinha feito algo parecido, respondeu que ela é uma menina tranquila, alegre e educada. Pois bem.

A própria ré SIMONE confessou a prática delitiva, tendo assumido que levou duas porções de maconha (já em formato de cigarros), a pedido de ALINE, na clínica onde esta estava internada, explicando que a droga estava dentro de uma jaqueta que a própria ALINE havia lhe emprestado anteriormente.

Destaco que em solo policial, SIMONE afirmou que sequer sabia a respeito da existência de tais entorpecentes na jaqueta, antes de ALINE os solicitar.

Além disso, em juízo, SIMONE afirmou que ALINE lhe pediu para levar os entorpecentes para que fizessem uso juntas, na hora do jantar.

Sobre a dinâmica da ocorrência, esclareceu que entregou a jaqueta para ALINE e que ela a guardou no quarto que ocupava na clínica aqui. Em seguida, saíram para almoçar. Quando voltaram, souberam por Sabino que alguém havia entrado no quarto de ALINE, pegado um cigarro de maconha e fumado, o que ALINE acabou confirmando.

a testemunha Sabino não presenciou a ocorrência, não conversou com SIMONE e, ao que soube dizer, referida ré não teria entrado na clínica. Explicou que ocorreu uma visita da mãe, do marido e de uma amiga de ALINE, sendo que esta corré teria solicitado anteriormente, via WhatsApp, que a amiga SIMONE lhe levasse maconha.

A testigo narrou que a droga foi levada dentro de flores. Confirmou que conseguiram pegar o entorpecente, explicando, contudo, que um paciente fez consumo da droga.

Diferentemente de Sabino, a testemunha Marielle estava na clínica e esclareceu que foi chamada por conta de movimentação anormal no quarto dos pacientes, sendo que ao adentrar o cômodo, sentiu o cheiro característico de maconha. Explicou que ao indagar o que ocorria, os pacientes desconversaram e que, considerando o ocorrido, comunicou ao médico psiquiatra o que estava acontecendo.

Narrou que o paciente foi chamado para conversar e confessou que havia consumido maconha, a qual teria pedido por meio de ALINE que, por sua vez, conseguiu a droga por meio de uma amiga dela – no caso, a ré SIMONE. Não se recordou ao certo sobre como a droga entrou no estabelecimento, dizendo acreditar que foi num buquê de flores. A testemunha confirmou que SIMONE admitiu que ALINE havia feito o pedido de entorpecentes e que, por tal motivo, havia levado as drogas para ela.

Outra testemunha que estava presente no local era Marisa, que narrou que ALINE era paciente, estava internada e recebeu visita de SIMONE, que entrou com um grande buquê de Gérberas, envolto num invólucro rústico. A testemunha disse que não suspeitou do buquê por razão de ele estar muito bem embrulhado, tendo afirmado, entretanto, que a droga estava dentro de referido buquê.

Marisa afirmou que três pacientes fizeram uso da substância, ou seja, ALINE, Fernando e Lucas.

Em explicação sobre a dinâmica dos fatos, relatou que SIMONE distribuiu a droga

para ALINE, que foi quem pediu, para Fernando, que estava com ALINE e para Lucas, que visitou o quarto. A testigo confirmou que ALINE assumiu ter pedido o entorpecente e que SIMONE o levou, tendo confirmado, ainda, que ALINE assumiu ter distribuído entorpecente também para Fernando e Lucas, esclarecendo que ALINE disse ter se tratado de um pedido de Fernando.

Fernando, que estava em tratamento na clínica à época, também foi ouvido, e relatou que presenciou ALINE recebendo de uma amiga (no caso, SIMONE) três ou quatro cigarros de maconha. Confirmou, ainda, que recebeu um cigarro de ALINE, tendo asseverado que Lucas também estava no quarto e consumiu o entorpecente.

Fernando foi indagado se ALINE fez consumo de maconha em outro quarto, ao que respondeu que sim. A testemunha afirmou que a amiga de ALINE, ou seja, SIMONE, levou as drogas para dentro da clínica num buquê de flores, ao que soube dizer. Como se observa dos depoimentos, é indubitável que SIMONE adentrou a clínica de reabilitação em questão com cigarros de maconha, os quais foram pedidos por ALINE, que estava sob tratamento na clínica. E mais: SIMONE não só adentrou o estabelecimento com os cigarros de maconha, como ainda os entregou a consumo de sua amiga.

Por si só, a conduta já consubstanciou tráfico de entorpecentes, senão vejamos: O artigo 33 da Lei 11.343/06 não define como necessário, para a consumação de suas figuras típicas, o caráter comercial do tráfico. Aliás, sequer delimita qualquer definição para “traficante”, limitando-se a descrever figuras típicas que, praticadas, ensejam penalidade.

In verbis:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa” (Lei nº 11.343 de 23 de agosto de 2006).

Optei por destacar, na transcrição acima, justamente a conduta descrita na denúncia, a qual foi perpetrada pela ré, bem como o restante do dispositivo, para demonstrar que não há, na Lei, qualquer menção sobre a necessidade de se evidenciar a finalidade mercantil do entorpecente, não havendo, ainda, descrição do que venha a ser a figura do traficante.

Curial destacar que a ação descrita no artigo 28 da Lei 11.343/06 dispõe que “Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...)” (destaquei e grifei), estará sujeito às sanções previstas naquele dispositivo.

Este artigo, sim, aponta uma finalidade específica: o consumo pessoal. Assim, a comprovação de que a droga era destinada ao consumo pessoal cabe àquele que faz a alegação, conforme a regra estampada no artigo 156 do Código de Processo Penal, sendo que a própria ré, em seu interrogatório, confessou que levou o entorpecente à clínica a pedido de sua amiga ALINE, para ela, não para consumo pessoal de SIMONE. A finalidade, portanto, outra não era senão a de trazer consigo e entregar a consumo, gratuitamente, droga a pessoa que se encontrava em clínica para reabilitação.

A conduta perpetrada pela ré se amolda perfeitamente no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, não havendo, portanto, que se falar em atipicidade da conduta.

E é fato que a conduta praticada não se adequa ao parágrafo 3º, do artigo 33, da Lei 11.343/06 que dispõe, in verbis:

“Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem”

Tem-se que o núcleo do tipo penal em questão é a ação de “Oferecer”, do que se conclui que a ação parte daquele que já detém o entorpecente.

SIMONE trouxe consigo e entregou a droga a consumo, gratuitamente, à corré ALINE, que foi, segundo a própria confissão de SIMONE, quem havia adquirido o entorpecente

anteriormente (tendo referida ré ressaltado, em seu interrogatório policial, que sequer sabia da existência dos entorpecentes no casaco antes de ALINE lhe dizer). E é fato que a conduta não se limitou a oferecer droga a pessoa de seu relacionamento para consumo. A testemunha Fernando relatou claramente que havia solicitado drogas a ALINE que, por sua vez, disse que as conseguiria por meio de uma amiga – justamente SIMONE, que levou o entorpecente para a clínica a pedido de ALINE, e não para oferecer a droga para uso conjunto. Não há que se falar, ainda, em princípio da insignificância, considerando-se que tal princípio, conforme reiterados julgados em instâncias superiores, não se aplica ao gravíssimo crime de tráfico de entorpecentes.

Sobre o tema, recente decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior 'de que afigura-se inaplicável o princípio da insignificância ao delito de tráfico ilícito de drogas, porquanto trata-se de crime de perigo presumido ou abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente' (EDcl no HC 463.656/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 24/10/2018). 2. Agravo regimental não provido”. (Processo AgRg no HC 709941 DF 2021/0384461-8; Órgão Julgador: T5 – Quinta Turma; Publicação: DJe 26/04/2022; Julgamento: 19 de abril de 2022; Relator: Ministro Ribeiro Dantas) (destaquei)

Por meio do laudo químico-toxicológico (fls. 34/35), verificou-se que a substância apreendida, tetrahidrocannabinol (THC), é de uso proscrito no Brasil.

Desta forma, considerando-se que a própria ré SIMONE assumiu ter levado o entorpecente à clínica, a pedido de ALINE, e analisadas as provas da forma com a qual se fundamentou a sentença ora prolatada, não resta ao juízo dúvida de que a ação praticada pela ré ora julgada consubstanciou tráfico ilícito de entorpecentes, não restando tese defensiva apta a afastar a condenação que se amolda.

A autoria do tráfico se revelou certa e deve ser atribuída à ré, que praticou a conduta prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

E não é só.

A prática foi levada a efeito nas dependências de nosocômio “Comunidade Terapêutica Maxwell”, em que se empreende serviço de tratamento de dependentes de drogas.

Incide, portanto, no caso em pauta, a causa de aumento específica prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, descrita na denúncia.

Reconhecidas materialidade e autoria com relação à corré SIMONE, passo a dosar sua pena.

Na dosagem da pena devem ser levadas em consideração as diretrizes do art. 59 do Código Penal. No entanto, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

A ré é tecnicamente primária (fls. 187).

Culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar. Pouco se sabe sobre sua conduta social ou personalidade, motivo pelo qual deixo de valorá-las. Quanto aos motivos do crime, os comuns ao tráfico. A consequência do delito revelou-se grave, posto que a testemunha Marisa relatou que um dos internos teve surtos psicóticos após o uso da droga levada até a clínica, local que visa, justamente, recuperação de toxicômanos. É circunstância obviamente grave, e totalmente previsível, que enseja recrudesimento da pena-base. Quanto à natureza e quantidade do produto, apurou-se que SIMONE trazia consigo e entregou a consumo dois cigarros de maconha. Assim, com base no exposto nesta primeira fase da dosimetria, considerando a consequência do delito praticado, fixo a pena acima do mínimo legal, em 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Quanto ao valor da diária, a ré afirmou auferir R\$ 4.000,00 mensais, trabalhando como cabeleireira. Considerando que o valor da diária deve corresponder a 1/30 dos rendimentos da ré, fixo o dia multa em R\$ 133,00. O valor total da pena de multa deverá ser atualizado em consonância com o art. 49, § 2º, do Código Penal.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes, nem atenuantes.

Embora a ré tenha admitido ter ingressado no estabelecimento com os entorpecentes, conforme pedido da corré ALINE, em evidente tese de defesa embutida, alegou que o fez para que consumissem juntas, versão que logicamente restou infirmada pela prova produzida.

Assim, ocorreu a chamada confissão qualificada, de forma que não poderá beneficiar-se da atenuante prevista na alínea 'd', do inciso III, do art. 65, do Código Penal. Confissão qualificada é aquela que ocorre quando o réu admite uma parte dos fatos criminosos, mas nega ou altera outra, exatamente como na hipótese, visando beneficiar-se.

Neste sentido: "CONFISSÃO ESPONTÂNEA - Circunstância atenuante - Inadmissibilidade - Hipótese em que o réu não assinala certos caracteres do fato criminoso - Caracterização de confissão qualificada" (RT 741/558).

Assim, mantenho a pena no patamar fixado.

Na terceira e última fase da dosimetria penal, fez-se presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, já que o delito foi praticado no interior de estabelecimento hospitalar dedicado à reabilitação de dependentes químicos. A pena é aumentada em 1/6, atingindo 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa.

Possível o reconhecimento causa de diminuição prevista no parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei 11.343/06. A ré é primária, não ostenta Maus antecedentes, nem há indícios de que se dedique a atividades criminosas relacionadas ao tráfico ou integre organização criminosa.

A diminuição, consideradas as circunstâncias particulares do delito em questão, será aplicada no patamar máximo, em 2/3, atingindo, a pena, o montante de 02 anos, 03 meses e 06 dias de reclusão e 226 dias-multa, pena que torno definitiva, inexistindo outras circunstâncias agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição da pena.

Em que pese a pena aplicada e as circunstâncias judiciais observadas, o juízo entende que ao delito de tráfico, o regime prisional não deve ser outro, senão o fechado.

O tráfico de entorpecentes é das atividades mais danosas ante o seio social hodierno. Sua prática atinge diretamente direitos e garantias fundamentais das pessoas, além de fomentar outros tipos de atividades ilícitas. Causa, ainda, direta e indiretamente, considerável mobilização estatal, atingindo, por consequência, o erário público, que tem de arcar com as custas de policiamento ostensivo, seja preventivo ou repressivo, campanhas de conscientização - sobre o óbvio, diga-se -, tratamento de saúde aos adeptos do uso contumaz, dentre outras inúmeras situações relacionadas, as quais requerem pronta ação do Estado.

Isto, entretanto, custa dinheiro e onera o contribuinte.

Seria um contrassenso o mesmo Estado que luta para combater tão nefasta prática - a tão altos custos - permitir que seu principal responsável retorne à liberdade sem experimentar a necessária punição e, principalmente, sem que de seu ato se arrependa, sobre ele reflita e o corrija, podendo criar, em última análise, a aplicação de regime mais brando, verdadeira sensação de impunidade, capaz, inclusive, de ensinar ao condenado mais um motivo para que torne à rentável prática.

Nem se diga haver o pequeno traficante, sobre quem recairia todo o peso da mão Estatal, e o grande traficante, que se ocultaria na hierarquia da coalizão narcotraficante, como tentativa de justificar atos injustificáveis. A Lei coíbe o tráfico e este existe por duas razões: porque alguém consome o produto e, principalmente, porque alguém o vende - eis a figura daquele que trafica, independentemente de sua posição hierárquica.

A ação do indivíduo encarregado de disseminar a substância entorpecente - geralmente identificado como o "pequeno traficante" - deve ser entendida como parte integrante e crucial do conjunto responsável pela narcotraficância: é ele que, por meio de sua ação, viabiliza o comércio "varejista" das drogas, fomentando o consumo e a própria continuidade da produção de entorpecentes, consubstanciando, sua atividade, não só o meio de sustento próprio, mas de toda a cadeia criminosa ligada ao narcotráfico - prática delitiva que domina a maior parte dos debates sobre

segurança pública e que consiste, em verdade, no cerne financeiro das atividades criminosas em geral.

É do espírito da Lei combater o tráfico ilícito de entorpecentes, seja ele praticado pelo iniciante – a quem é conferido algum tipo de benefício, conforme se observa do parágrafo 4º, do artigo 33, Lei 11.343/06 – pelo gerente de “boca” ou por associados a organizações criminosas – pessoas a quem a Lei trata de maneira especial e mais severa. O fato é que o tráfico, independentemente do tipo de atuação de seu praticante, merece reprimenda exemplar.

Sobre todo o tema até então debatido, uma brilhante manifestação oriunda do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“(…) Não se olvide da recente decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo, em caráter incidental, a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos, que estabelece o cumprimento da pena em regime inicialmente fechado, aos agentes condenados por crimes hediondos e equiparados (STF, 111.840/ES, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado de 27-06-12), todavia, a norma citada está em pleno vigor e a recente decisão da Suprema Corte não impõe de forma obrigatória o acatamento do novo entendimento. Registra-se ainda que o Excelso Supremo Tribunal Federal recentemente também reconheceu, de modo incidental, a inconstitucionalidade da expressão “vedada a conversão em pena restritiva de direitos” constantes dos artigos 33, § 4º e 44 da Lei Antidrogas. Esse reconhecimento de inconstitucionalidade, todavia, não implica substituição automática da pena de prisão por pena restritiva de direitos. Na decisão é ressaltada a possibilidade de o julgador analisar, em cada caso concreto, a viabilidade e admissibilidade dessa substituição. Tal como veiculado de forma contínua nos diários de grande circulação no país, o tráfico de drogas vem se tornando assustadoramente contumaz no cotidiano das grandes, médias e até mesmo pequenas cidades, inclusive aquelas incrustadas nos mais distantes rincões da nação. Não há distinção entre ricos ou pobres, raça ou religião; o comércio ilegal avança de forma incontrolável, ora favorecido pela insuficiência policial, ora beneficiado pelo abrandamento do rigor penal. Evidentemente o grande traficante, o responsável pela distribuição da droga em determinada região ou cidade, não se envolverá diretamente na comercialização da droga; valer-se-á do jovem preterido pela sorte, disposto a lutar por algum dinheiro que propicie a imediata realização de necessidades básicas. Ocorre então a perfeita comunhão de interesses. De um lado, o responsável pelo tráfico, que se arrima em incautos jovens, inimputáveis pela tenra idade, ou de passado até então escorreito, para comercializar seu produto, e de outro o pequeno cidadão que, eventualmente detido pela prática espúria, poderá ser beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. O número expressivo de pessoas que poderiam ser servidas com as drogas, bem demonstra a periculosidade latente do réu, recomendando o cumprimento da pena no regime inicial fechado e obstando a substituição da pena por quaisquer das medidas alternativas. Portanto, acolho a pretensão do representante do Ministério Público e fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, tendo em vista que se trata do regime compatível com a conduta do acusado. Cumpre ressaltar ainda que as circunstâncias dos autos, a meu sentir, data máxima vênua, obstam a ingenuidade do reconhecimento de que se tratava de pequenos traficantes, mesmo porque esta simplória qualificação é permeada por um revés de complexidade. Qual a equação para se distinguir o grande traficante do pequeno comerciante? A quantidade de drogas apreendidas no momento da prisão? A constância da atividade do comércio ilegal? Cabe aqui outra indagação: não parece pouco provável que o grande traficante irá se aventurar a permanecer em um ponto de venda de entorpecentes, correndo riscos desnecessários, quando poderá se valer daquelas pessoas a quem a norma legal classifica como o pequeno traficante? A meu ver, e volto a repetir, sempre respeitando os posicionamentos em sentido contrário, quando se atribui ao infrator a condição de pequeno traficante, estar-se-á procurando combater sempre o efeito e não a causa de tão perverso delito, haja vista que aquele indivíduo considerado como o grande traficante dificilmente será detido, porque sempre contará com os préstimos do pequeno traficante. Não se pode ignorar também que o tal pequeno infrator, beneficiado por esta qualificação com

pena menos rigorosa, na maioria das vezes, voltará a reincidir na empreitada criminosa, pois a tal atividade delituosa basta a lhe proporcionar, sem maiores esforços, rendimento financeiro que raros cidadãos de bem chegam a alcançar em algum momento de suas vidas. E a consequência desta fartura financeira é previsível, ante a frouxidão do rigor penal, data máxima vênua, que de algum tempo a esta parte tem levado à concessão do regime aberto, e até mesmo à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, ao traficante de drogas, com o intuito óbvio de amenizar as amarguras do cidadão castigado pela incompetência do Estado, que, de forma implícita, os induz a lançar mão de meios espúrios para a sua sobrevivência. Entretanto, em que pese ser louvável o sentimento de humanidade, sobretudo com as pessoas mais preteridas pela sorte, não se pode olvidar o resultado funesto desta benesse, ou seja, a destruição de vidas, de laços familiares, da paz social, e o inquestionável incremento de delitos permeados de igual gravidade, ora por necessidade da obtenção de meios materiais para a satisfação da dependência química, ora diante da inconsciência, da inimputabilidade, causada pela droga, a tal ponto de levar uma pacata pessoa ao extremo de uma atitude inimaginável a um ser humano. Devo reconhecer que tenho sido voto vencido junto a meus pares, a cujos posicionamentos me curvo com a humildade esperada, e por isso mesmo, eventualmente, sou reconhecido como extremamente rigoroso, entretanto, não o faço como castigo, o que seria de todo despropositado e bem acarretaria o desvirtuamento da finalidade da pena. É imperativo ressaltar também que não tenho a menor intenção de negar vigência à norma legal ao não aplicar na maior parte das vezes - como Relator dos autos aos meus cuidados - o redutor previsto na Lei nº 11.343/06, mas entendo que a tanto é imprescindível a comprovação de que o agente também conte com algumas qualidades que devem permear a conduta do cidadão de bem, v.g., a participação efetiva de atividade escolar ou o exercício de trabalho lícito remunerado, e só assim, mas ainda com muito esforço, conseguiria visualizar a figura do pequeno traficante. (...)” (APL TJ-SP 0027320-18.2012.8.26.0224; Órgão Julgador: 4ª Câmara Criminal Extraordinária; Publicação: 18/01/2017; Julgamento: 14 de Dezembro de 2016; Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro).

Salutar a fundamentação, que reduz a termo o espírito buscado pela construção normativa do Legislador. É razão mais que suficiente para que se entenda que o praticante do tráfico de drogas deve permanecer afastado do convívio em sociedade. Ficam vedados, ainda, pelas mesmas razões, quaisquer outros benefícios, incluindo-se a substituição da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, tudo a indicar não ser referida conversão medida adequada e suficiente ao caso concreto. Assim é que se decide.

Centrada nestes fundamentos, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno SIMONE DE ARAUJO PORTO como incurso nas penas do artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 anos, 03 meses e 06 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 226 dias-multa, diária fixada em R\$ 133,00, com valor total da pena de multa atualizado nos termos do art. 49, § 2º, do Código Penal.

A ré respondeu o processo em liberdade e, não havendo alterações fáticas capazes de ensejar seu encarceramento provisório, poderá apresentar eventual recurso sem se recolher ao cárcere.

Transitada esta sentença em julgado, comunique-se a presente condenação à Justiça Eleitoral em atenção o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, EXPEDINDO-SE O COMPETENTE MANDADO DE PRISÃO OPORTUNAMENTE.

Por último, condeno a ré ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea “a” da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observada eventual gratuidade da Justiça.

No mais, cumpra-se o desmembramento ora determinado, bem como o quanto disposto a fls. 470.

P.I. e C.

Atibaia, 30 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA